

1501536-50.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501536-50.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501536-50.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2121342/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17715490 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1044/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2121342 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1044/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE AMBRÓSIO CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

LEONARDO HENRIQUE AMBRÓSIO CARVALHO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, em 04 de maio de 2021, por volta das 18h30min, na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, bairro Jardim Glória, neste município e comarca, o acusado adquiriu e transportava, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 27 grandes porções (em forma de tabletes) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando 24.179,43g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado adquiriu e recebeu grande quantidade de maconha para desenvolver o comércio ilícito de drogas em Limeira e cidades da região.

Na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que o condutor do veículo Fiat/Punto, cor cinza, placas FHY-7H96, iria buscar grande quantidade de entorpecentes na cidade de Campinas/SP. Em continuidade à diligência, os agentes públicos lograram avistar o momento em que referido automóvel retornou à cidade de Limeira e, então, realizaram a abordagem do veículo, que era conduzido pelo denunciado.

Em revista pessoal, foram encontrados dois aparelhos celulares com o denunciado. Em buscas pelo automóvel, os policiais militares encontraram, no banco traseiro do veículo, uma caixa de papelão contendo 27 tabletes de maconha. Informalmente, LEONARDO confessou que transportava drogas, momento em que ele foi preso em flagrante delito.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 149/151).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021 (fls. 153/155).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defensoria Pública ofertaram alegações finais.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo pericial com resultado positivo para maconha (fls. 30/33 e 114/116), laudo pericial de fls. 133/137, bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado manifestou o interesse de permanecer em silêncio (fls. 09).

Em Juízo, o réu disse que tem 22 anos. Tinha um lava-rápido. Tem um filho e morava junto com sua namorada. Um cliente ligou e perguntou se o lava-rápido estava vazio. Lavou o carro dessa pessoa. Foi esse cliente que deu a ideia dele buscar drogas em Campinas. Estava com o aluguel vencido. No momento de fraqueza aceitou fazer o transporte. Iria ganhar setecentos reais. Não sabia que droga era, nem a quantidade. Está arrependido. O veículo Fiat Punto era de sua propriedade, estava no seu nome. Não pode falar o nome das outras pessoas envolvidas, tem medo de ser retaliado e teme pela vida dos seus familiares. Não pode falar o nome do cliente. Confirmou o transporte (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial.

O policial militar Ivan Dias de Jesus disse que, na data dos fatos, faziam patrulhamento pelo bairro Santa Adélia. Uma pessoa os solicitou dizendo que três pessoas estavam em dois veículos e que eles iriam até Campinas buscar drogas. Foram

indicados os dois veículos envolvidos, quais sejam, um Fiat Palio e um Fiat Punto, e que estes iriam até Campinas para buscar grande quantidade de entorpecente. Em buscas aos emplacamentos repassados no Detecta, constatou que os dois automóveis tinham deixado Limeira ao mesmo tempo. Ficaram na entrada da cidade de Limeira com vistas aos veículos mencionados retornarem para cá. Depois, avistaram os dois veículos adentrando em Limeira, tendo abordado ambos. O veículo Punto era conduzido pelo acusado. Em revista pessoal efetuada em Leonardo, nada de ilícito foi encontrado. No banco traseiro do veículo, encontraram uma caixa de papelão contendo 27 tabletes com material semelhante à maconha, envolta em plástico da cor verde. Também encontraram dois celulares. O veículo Palio era conduzido por Carlos, tendo como passageiro Igor. Em revista pessoal feita nos dois, com Carlos foram encontrados dois celulares e quantia em dinheiro. Também foram encontrados nos dois veículos comprovantes de pagamento do pedágio de Nova Odessa, e foram computados poucos minutos de diferença de um veículo para o outro. Indagados, o acusado Leonardo confessou que teria droga no interior do veículo, mas disse não conhecer Carlos e Igor. Iria receber setecentos reais para buscar o entorpecente. Carlos e Igor, por sua vez, negaram que estivessem juntos com Leonardo e disseram não o conhecer. Diante dos fatos, conduziram todos ao plantão, juntamente com a droga, dinheiro, celulares e veículos. Não conhecia o réu e as outras pessoas. Leonardo não disse de onde pegou as drogas e nem qual era o destino (mídia).

O policial militar Edirlei Aparecido Narcizo contou que faziam patrulhamento pelo bairro Santa Adélia quando foram solicitados por uma pessoa dando riqueza de detalhes de carregamento de drogas. Três pessoas iriam buscar uma parada em Campinas. Os veículos e as placas foram repassados. Havia um Fiat Punto e um Fiat Palio envolvidos na prática criminosa. No sistema Detecta constatou que os dois automóveis saíram juntos pela Avenida Costa e Silva. Outras viaturas foram acionadas para patrulhar as entradas da cidade assim que os automóveis voltassem para Limeira. Fizeram saturação. Por volta das 18 horas, viram os dois veículos indicados entrando na cidade. Deram sinal de parada. No veículo Fiat Punto conduzido pelo réu encontraram uma caixa de papelão contendo 27 tabletes de maconha. Em busca veicular encontraram comprovante de passagem de Nova Odessa. Em busca veicular no Fiat Palio nada de ilícito encontraram. Havia dinheiro com Carlos e Igor. Leonardo foi preso por tráfico de drogas. Indagado, ele confirmou que seria o dono daquela droga e ganharia setecentos reais pelo transporte (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j.

28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas testemunhas de defesa.

A testemunha Aryadine Barros Cano disse que é namorada do acusado. Foi ouvida como informante. Não sabe nada a respeito dos fatos. Achou que o acusado estava trabalhando. Na época ele trabalhava no lava-rápido. Estão juntos há dois anos. Desconhece o envolvimento dele com o tráfico. Ficou surpresa com a prisão (mídia).

A testemunha Guilherme Santos disse que é amigo do réu e trabalhavam juntos. É amigo dele há mais de dois anos, criaram amizade por trabalhar juntos. Ambos trabalhavam no lava-rápido. Ficou sabendo da prisão no mesmo dia. Nunca ficou sabendo do envolvimento do seu colega com o tráfico. O réu tinha um lava-rápido (mídia).

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares receberam informação de que dois veículos iriam buscar grande quantidade de entorpecente em Campinas. Foram repassados as características dos automóveis e o emplacamento. A polícia militar foi acionada a fim de que fosse feita a abordagem no retorno a Limeira. Posteriormente, os agentes públicos avistaram o momento em que os referidos automóveis ingressaram na cidade.

Na abordagem, os guardas constataram que o réu estava conduzindo um dos veículos indicados. Em revista pessoal foram localizados dois aparelhos celulares. Na sequência os policiais efetuaram buscas no automóvel e encontraram no banco traseiro uma caixa de papelão contendo 27 tabletes de maconha. Informalmente o réu confessou que transportava drogas, de modo que ele foi preso em flagrante delito.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade e a natureza das drogas (maconha), a denúncia anônima, as circunstâncias da prisão, a confissão judicial e o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Note-se, ainda, que o acusado nada indicou de real para colocar dúvidas sobre a atuação dos policiais militares, pois eles sequer conheciam o acusado e a abordagem se deu após recebimento de denúncia anônima envolvendo o automóvel conduzido pelo acusado.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do

mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem.

Não é caso de reconhecimento de agravantes e atenuantes. A pena já foi fixada no mínimo legal, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 não deve ser aplicada. Com efeito, observo que o réu denota dedicação à atividade criminosa em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida em seu poder, com o encontro de 27 grandes porções de maconha pesando mais de vinte e quatro quilogramas, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei em tais circunstâncias.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente que adoto como razão de decidir: "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (...) 5. Dosimetria da pena 6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). 7. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas deve ser o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, bem como em razão das particularidades do caso concreto. Precedente do STF. Além da quantidade da pena imposta. 9. Provimento do recurso Ministerial, com expedição de mandado de prisão". (TJSP; Apelação 0004783-35.2014.8.26.0296; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é na mesma direção:

"(...) III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e

a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos (865,8 g de maconha e 3,4 g de cocaína), e nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, em decorrência de denúncia de sua genitora de que aquele guardava um tablete de maconha em sua residência) e a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas e a outra parte encontrada em sua residência, juntamente com tesoura e faca com resquício de cocaína e dinheiro em notas miúdas), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 568.062/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

"(...) 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp n. 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; HC n. 385.437/SP, de minha relatoria, DJe 27/3/2017; HC n. 324.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 8/3/2016. 3. Com relação ao pleito de aplicação da redutora para incidir a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 4. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de 20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, acondicionada em 19 "tijolos", e 254, 850 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo que se falar em bis in idem (e-STJ fl. 492/493). Assim, fica evidenciada fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 5. Por sua vez, em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016. In casu, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

"3. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem

reconhecidamente primários, possuem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Hipótese em que as instâncias antecedentes mantiveram afastada a minorante, por entender que a entrega de gigantesca quantidade de drogas pelo paciente - 29 tijolos de cocaína (28,159 kg) -, não deixa dúvida do seu envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes. Assim, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (...) 6. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza das drogas apreendidas), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. O tema relativo à concessão de regime domiciliar por motivo de doença respiratória não foi debatido na Corte de origem, o que impede a sua análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de origem, observa-se que, em 2/2/2021, certificou-se o trânsito em julgado da condenação. 8. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 552.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade da droga em discussão (27 grandes porções de maconha pesando mais de 24 kg), sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Diante das provas carreadas aos autos (transporte de maconha entre cidades diversas), declaro o perdimento do veículo Fiat/Punto, cor cinza, placas FHY-7H96, em favor da União, que posteriormente será revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, assim como dos demais objetos apreendidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LEONARDO HENRIQUE AMBRÓSIO CARVALHO, qualificado nos autos, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do veículo Fiat/Punto, cor cinza, placas FHY-7H96, assim como dos demais bens apreendidos.
Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Limeira, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA